

CRIMES CONTRA PESSOA - ARTS. 124 A 128 - ABORTO

Obs.: o aborto é a retirada da vida de um feto que se encontra na barriga da mãe. Tira-se a perspectiva da vida de uma pessoa; por isso, esse crime é punido dentro do capítulo de crimes contra a vida (art. 124 a 126, Código Penal).

Aborto – artigos 124 a 129

- **Objeto jurídico:** vida humana

Obs.: objeto jurídico é aquilo que a lei visa proteger. Nos crimes de aborto, a lei visa proteger a vida humana. O feto tem a perspectiva de vida. Portanto, o objeto jurídico é a vida humana.

- **Objeto material:** feto.

Obs.: objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. No aborto, a conduta criminosa recai sobre o feto. O objeto material é o feto. É preciso fazer apenas uma ressalva. No art. 125, que dispõe sobre o aborto sem consentimento da gestante, o sujeito passivo e objeto material serão a integridade física e psíquica da gestante.

- **Termo inicial da gravidez:** fecundação.

Obs.: o momento é a fecundação. É o momento em que o espermatozoide se insere no óvulo da mulher.

E as pílulas do dia seguinte e os métodos contraceptivos que atuam após a fecundação do espermatozoide no óvulo da mulher? A fecundação é o termo inicial da gravidez. A partir desse momento pode haver – e haverá – o crime de aborto se a mulher ou outra pessoa tiverem a intenção de retirar o feto. No entanto, no que concerne à pílula do dia seguinte e aos métodos contraceptivos que atuam após a fecundação, existe uma hipótese da exclusão da ilicitude: o exercício regular do direito. A lei permite. Em que pese já estar fecundado o óvulo, a lei permite o uso desses métodos contraceptivos. Ao ingerir uma pílula do dia seguinte, existe o fato típico do aborto; no entanto, não é ilícito, pois está presente a excludente da ilicitude do exercício regular do direito.

ANOTAÇÕES

Portanto, o termo inicial da gravidez é a fecundação, de acordo com a maior parte da doutrina e da jurisprudência, mas, no que concerne a métodos contraceptivos que atuam após a fecundação, será exercício regular do direito (hipótese de excludente de ilicitude prevista no art. 23 do Código Penal).



- **É possível se falar no crime de aborto culposo?**

Obs.: sabe-se que toda gestante é aconselhada a não fumar. Suponha que tenha uma gestante que fume e seja viciada. Imagine que, em razão do cigarro que ela fuma, o bebê é abortado. Ele perde o feto em razão do cigarro. Ela responde pelo crime? Não existe a possibilidade de aborto culposo. Essa mãe foi imprudente ao fumar cigarro. No entanto, o Código penal não prevê a modalidade culposa no crime de aborto; logo, essa mãe não poderá ser responsabilizada pelo crime de aborto. Ela não teve o dolo voltado para a perda do feto. Ela não teve a intenção de abortar. Ela agiu de maneira culposa. Pode-se até falar que foi uma culpa previsível, mas, mesmo assim, não será atribuído o crime de aborto a essa mãe. Para que o crime de aborto seja atribuído a um determinado agente, o elemento subjetivo deve ser o dolo (ou, pelo menos, o dolo eventual).

Portanto, não é possível se falar em crime de aborto culposo.

- **É possível a prática do crime de aborto por omissão? Sim.**

Obs.: essa omissão é a omissão do art. 13, § 2º, Código Penal (aquele que tem o dever legal de agir, aquele que é o garante, aquele que deve atuar em razão de ingerência). É a omissão imprópria.

É possível a prática do crime de aborto por omissão. Exemplo: suponha que uma mãe queira abortar. Ela sabe que, caso ela não se alimente por cinco dias, ela perderá o feto. Ela passa cinco dias sem comer. Ela está praticando uma inação, uma conduta omissiva. Ela está deixando de cuidar e de agir para proteger o feto. Ela para de se alimentar e, em razão disso, perde o filho (aborta o feto). Ela teve o dolo voltado para o aborto. Ela agiu de maneira dolosa. Em vez de agir de maneira comissiva (praticando uma ação positiva, uma manobra abortiva), ela simplesmente parou de comer. Por meio de uma omissão imprópria, ela praticou o crime de aborto e será responsabilizada porque essa foi sua intenção e ela buscou esse resultado por meio da sua inação, da sua omissão. É uma hipótese de crime omissivo impróprio, também chamado de crime comisso por omissão.

Código Penal, Capítulo I – Crimes contra a vida

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:
Pena – detenção, de um a três anos.

Obs.: o art. 124 apresenta duas condutas distintas. Em comum entre os dois, pode-se dizer que são crimes de mão-própria. Os crimes de mão-própria são aqueles cuja conduta não pode ser delegada a outra pessoa. O crime de provocar aborto em si mesma só pode ser praticado pela mãe; no crime de consentimento para o aborto, a única pessoa que pode consentir é a mãe. Logo, são crimes de mão-própria, conforme entendimento majoritário da doutrina.



10m

É importante entender a distinção entre o autoaborto (provocar aborto em si mesma) e o consentimento para o aborto.

Autoaborto: os crimes de mão-própria não admitem coautoria. No entanto, eles admitem a participação. Exemplo: a gestante quer abortar, fala ao namorado, que concorda. A gestante faz uma pesquisa na internet e pede que o namorado compre alguns remédios para abortar. O namorado compra os remédios. Ela praticou autoaborto (art. 124, Código Penal). O namorado foi um partícipe, prestou auxílio material para que a gestante praticasse a conduta do art. 124. Portanto, os crimes de mão-própria e as hipóteses do art. 124 do Código Penal não admitem coautoria, pois só podem ser praticados pela mãe, mas admitem a participação.

No caso de “consentimento para o aborto”, entende-se que é uma exceção pluralística. Trata-se de concurso de pessoas. O Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária. Quando um, duas ou vinte pessoas concorrem para a prática de um crime, todas elas respondem pelo mesmo crime. Existem raras hipóteses de exceções pluralísticas. Exemplo: existem dois ou mais agentes concorrendo e buscando determinado resultado. Eles estão buscando o mesmo resultado, mas, nessas exceções, eles respondem por crimes distintos. Imagine que uma gestante queira abortar e procure uma clínica clandestina. Ela fala ao “cara que pratica aborto” e diz que quer abortar. Ele realiza manobras para que a mulher aborte. A gestante praticou o crime do art. 124, segunda parte (ela consentiu que outra pessoa provocasse o aborto). Será uma exceção pluralística porque o cara que praticou o aborto não pode responder pelo art. 124. Foi ele quem realizou as manobras abortivas; logo, ele não pode ser considerado um mero partícipe do consentimento da gestante. Ele praticou um crime descrito no art. 126 do Código Penal (provocar o aborto com o consentimento da gestante). A pena é mais grave para aquele que executa o aborto do que para a gestante que consente para o aborto.



15m

Conforme observado pela pena, o crime do art. 124 é um crime de médio potencial ofensivo e admite a suspensão condicional do processo. Para a gestante, a pena é de detenção.

Aborto provocado por terceiro

Obs.: os arts. 125 e 126 são abortos provocados por terceiros. No art. 125, o aborto é provocado por um terceiro sem o consentimento da gestante; no art. 126, o aborto é provocado com o consentimento da gestante. Quando houver o art. 126, haverá a gestante praticando o art. 124, segunda parte. Quando houver uma gestante praticando o art. 124, segunda parte, haverá uma exceção pluralística e aquele que tiver executado aborto responderá pelo art. 126 do Código Penal. Portanto, o art. 126 também será uma exceção pluralística (provocar aborto com o consentimento da gestante).

Art. 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

Pena – reclusão, de três a dez anos.

Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante:

Pena – reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.

Obs.: de acordo com a pena, o art. 126 é um crime de médio potencial ofensivo. O parágrafo único deixa claro que o consentimento deve ser válido. O Código Penal tem diversos exemplos mostrando que menores de 14 anos não podem consentir a nada. Caso um menor de 14 anos pratique ato sexual, será um estupro de vulnerável com quem ele pratica. Portanto, se o aborto for praticado em uma gestante menor de 14 anos, ainda que ela tenha consentido, esse consentimento não é válido. Aquele que tiver executado um aborto em um menor de 14 anos débil mental, mediante fraude, grave ameaça ou violência responderá pelo art. 125 (aborto sem o consentimento da gestante).

No art. 125, a pena é bem maior (reclusão, de três a dez anos); logo, crime de elevado potencial ofensivo. O crime do art. 125 tem uma dupla subjetividade passiva. Isso significa que há dois sujeitos passivos no crime, duas vítimas. As duas vítimas são o feto e a gestante. É um crime comum, qualquer pessoa pode vir a praticar o crime de aborto sem o consentimento da gestante.



20m

ANOTAÇÕES

Exemplo: em um casal de namorados, a menina ficou grávida e queria ter o filho, mas ele não. Ele dissolveu remédios abortivos na bebida dela. Quando ele bebeu, ela perdeu o feto. No hospital, explicaram sobre os remédios e ficou provado que o namorado havia dado os remédios. É mais um exemplo de aborto sem o consentimento da gestante. O namorado responderia pelo crime de aborto por terceiro sem o consentimento dela.

Forma qualificada

Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.

Obs.: o Código Penal está errado ao colocar “forma qualificada”. O art. 127 dispõe uma causa de aumento de pena. A forma qualificada é quando a lei atribui uma pena específica. O art. 127 é bem claro ao dispor que é uma causa de aumento de pena (a pena será aumentada em 1/3).



25m

O art. 127 aplica-se aos arts. 125 e 126. O termo “lesão corporal de natureza grave” está em sentido amplo e vai se aplicar tanto se a gestante sofrer lesão corporal grave (art. 129, § 1º) quanto se ela sofrer lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º).

É interessante reparar que essas causas de aumento de pena do art. 127 não se aplicam à gestante quando ela provoca o aborto em si mesma (autoaborto). Caso uma gestante tome um remédio abortivo e, em razão do remédio, gere em si própria uma lesão corporal grave ou gravíssima, ela não responde por essa causa de aumento de pena. Ela responde pelo aborto ou tentativa de aborto, mas não responde em razão da lesão corporal grave que causou em si mesma, pois isso contrariaria o princípio da alteridade.

O art. 127 dispõe hipóteses preterdolosas, ou seja, há dolo na conduta e culpa no resultado (dolo no antecedente e culpa no consequente). O dolo é voltado para o aborto, mas, mediante culpa, acaba sendo gerada uma lesão corporal grave ou a morte da vítima. São hipóteses preterdolosas porque o dolo da conduta é voltado unicamente para gerar aborto, mas, em razão da manobra abortiva, por culpa (negligência, imprudência, imperícia), acaba gerando lesão corporal grave ou gravíssima ou a morte da vítima.

O art. 127 é aplicável ainda que o aborto não seja consumado.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Ultimamente, o que mais tem sido cobrado em prova é o art. 128.



30m

Hipóteses em que o aborto não é crime

Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico:

Obs.: o art. 128 dispõe sobre causas especiais de exclusão da ilicitude. Existem as causas genéricas da excludente de ilicitude, como estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Além dessas, existem as causas específicas, especiais. Nessas causas especiais, há a previsão de situações em que o aborto não é considerado crime.

Aborto necessário

I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Obs.: a doutrina também chama o aborto necessário de **aborto terapêutico**. Há o conflito entre dois valores fundamentais: de um lado, a vida da gestante; de outro lado, o feto que tem perspectiva de vida. A lei entende que, nesse caso, é preciso priorizar a vida da gestante. Portanto, para que haja essa causa de excludente de ilicitude, é preciso que haja dois requisitos: vida da gestante em risco; não há outro meio de salvá-la. O risco não precisa ser presente, atual. Pode ser que o médico constate que, caso a gravidez prossiga, a gestante irá morrer no parto. É um risco futuro. É possível se antecipar e realizar o aborto antes de chegar à situação de risco.

Não é possível provocar o aborto em razão da **saúde** da gestante. A lei deixa claro que, se há um risco para a **vida** da gestante, o aborto pode ser provocado. No entanto, caso seja um risco para a saúde (exemplo: a gestante tende a desenvolver diabetes durante a gestação), não é possível realizar o aborto; caso haja risco de **vida**, é possível.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Não se pune o aborto praticado por **médico**. Uma mulher gestante não pode ir a uma clínica clandestina, consentir para o aborto e alegar posteriormente que fez isso somente pois havia risco de vida. Ela também não pode ingerir remédios abortivos porque existe risco a sua vida. Esse aborto, obrigatoriamente, deve ser praticado por um médico (I e II).



35m

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

Obs.: a doutrina chama esse tipo de aborto de aborto humanitário, sentimental, ético.

Portanto, há, de novo, dois requisitos: a gravidez precisa resultar de estupro (inclui estupro de vulnerável); consentimento válido.

ATENÇÃO

Nessa segunda hipótese, o aborto é resultante de uma gravidez de estupro. **Não exige autorização judicial. Não exige a condenação do autor.** Para realizar o aborto, o médico precisa de provas de que o aborto realmente foi praticado mediante um estupro. Às vezes, para isso, é possível usar: boletim de ocorrência, oitiva da vítima, caso notório.



40m

3ª) Interrupção da gravidez de feto anencéfalo (anencefalia)

Obs.: anencefalia é quando não é gerada a caixa craniana. Não tem cérebro, em ditos populares, o feto. O STF entendeu que, em razão dessa condição, não há expectativa de vida. É direito da mãe abortar o feto, pois não há expectativa de vida e não atinge o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Na ADPF 54/DF, o STF decidiu que a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta atípica.

ANOTAÇÕES

Fundamentos:

1) De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o anencéfalo é um natimorto cerebral, portanto é um feto inviável. Nesse entendimento, o anencéfalo não possui vida humana – perspectiva do feto.

2) Dignidade da pessoa humana – perspectiva da gestante.

Obs.: a hipótese acima é pacífica na jurisprudência. Portanto, o feto anencéfalo pode sofrer aborto. Não é considerado crime de aborto a gestante que aborta um feto com anencefalia.

***4ª) Interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação**

No HC 124306, a 1ª Turma do STF decidiu por uma quarta exceção: a interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação (julgado em 29/11/2016. Info 849). Houve manifestação por maioria nesse sentido.

Obs.: essa quarta hipótese está marcada com um asterisco. Houve uma decisão do STF, encabeçada pelo ministro Barroso, no sentido de permitir o aborto realizado dentro do primeiro trimestre. É preciso cuidado, pois o entendimento ainda não é pacífico.

Homicídio de mulher visivelmente grávida ou que o agente tem conhecimento da gravidez

Obs.: suponha que João mate uma gestante, sabendo que ela estava grávida. O simples fato de ele ter conhecimento de que ela era gestante e matá-la fará com que ele responda por ambos os crimes, em concurso formal impróprio (imperfeito). Ele responde pela pena de homicídio e pelo aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante.

Concurso formal impróprio (imperfeito) entre homicídio (art. 121, CP) e aborto provocado por terceiro (art. 125, CP)

HC 191.490-RJ, julgado em 27/09/2012

ANOTAÇÕES



Aborto de gêmeos ou trigêmeos

A doutrina entende que haverá dois ou três crimes de aborto em concurso formal impróprio (imperfeito), desde que a(o) agente tenha conhecimento dessa condição.

Obs.: o concurso formal impróprio (imperfeito) é mediante uma ação, o agente pratica dois ou mais crimes e havia desígnios autônomos.

Hipóteses proibidas de aborto – geram responsabilização penal

Aborto eugênico: aborto cometido em razão de uma má formação do feto.

ATENÇÃO

Já houve prova que tentou enganar afirmando que o aborto eugênico era permitido. Ele não é admitido no Brasil.

Aborto miserável, econômico, ou social: aborto praticado pela agente que não vislumbra possuir condições financeiras adequadas para criar um filho.

Aborto *honoris causae*: aborto para esconder a gravidez originária de uma relação extramatrimonial.

ATENÇÃO

Processos que serão julgados pelo STF nos próximos meses/anos:

ADI 5581/DF – pugna pela permissão para abortar feto vítima de microcefalia (deficiência na caixa craniana)

Obs.: lembre-se: somente é permitido o aborto nos casos de anencefalia (ausência de caixa craniana, ausência de cérebro). Quando há a deformidade (microcefalia), não é admitido, hoje, o aborto.

ADPF 442/DF – pugna pela não punição do aborto praticado pela gestante até a 12ª semana de gestação.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.